

1500365-45.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/08/2022

... 0004211-84.2014.8.26.0456, pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 16/03/2017; b) autos nº 0000428-26.2010.8.26.0456, pelo crime de furto, tendo a sentença transitado em julgado em 16/01/2012; c) autos nº 0003871-19.2009.8.26.0456, pelo crime de furto, cuja sentença transitou em julgado em 09/12/2012; d) autos nº 0003695-40.2009.8.26.0456, pelo crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500365-45.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500365-45.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110151/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 17490214 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 478/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2110151 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

A ilustre Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA, brasileiro, RG nº 29343363/SP, CPF 206.309.118-86, natural de Junqueirópolis, nascido aos 06/02/1978, filho de Maria Aparecida Xavier da Silva e de José Carlos da Silva, residente na Rua Florisvaldo Ribeiro de Bessa, nº 84, Jardim Morada do Sol, Pirapozinho/SP; e, LUIZ GUSTAVO CAETANO DA SILVA, brasileiro, RG nº 47471151/SP, natural de Pirapozinho/SP, nascido aos 02/09/1990, filho de Devanir Caetano da Silva, residente na Rua Florisvaldo Ribeiro de Bessa, nº 84, Jardim Morada do Sol, dando-os como incursos nas sanções previstas no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta, dos inclusos autos que, no dia 22 de abril de 2021, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial localizado na Rua Rui Barbosa, nº559, Centro, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA, apelido "Sonora", qualificado às fls. 08, juntamente com LUIZ GUSTAVO CAETANO DA SILVA, qualificado as fls. 07 dos autos nº 1500372-37.8.26.0583, previamente ajustados e em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços para a obtenção de um resultado comum, subtraíram, por duas vezes, para eles, a quantia aproximada de R\$400,00 (quatrocentos reais), um aparelho de telefone celular e diversos gêneros alimentícios, pertencentes à vítima Luiz Umberto Feba Fernandes Junior.

Conforme o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado CARLOS estava na companhia do denunciado LUIZ GUSTAVO, quando percebeu que a chave do estabelecimento comercial onde funciona uma pizzaria estava na fechadura da porta e ambos decidiram ingressar no local.

O denunciado CARLOS permaneceu do lado de fora, enquanto LUIZ GUSTAVO ingressou no estabelecimento e subtraiu o dinheiro que estava no caixa. Após a subtração, os autores foram para a casa do denunciado CARLOS.

Posteriormente, de comum acordo, eles decidiram furtar mais objetos, ocasião em que LUIZ GUSTAVO retornou sozinho ao estabelecimento comercial, e subtraiu diversos gêneros alimentícios e guardou-os na casa do denunciado GUSTAVO.

Durante diligências visando à apuração dos fatos, os denunciados foram reconhecidos como sendo os autores do furto e, na residência de GUSTAVO, foi localizado parte dos objetos subtraídos.

Os acusados foram presos em flagrante e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 62/66).

A denúncia foi oferecida em. 05/05/2021, abrangendo, também, os fatos objeto do Auto de Prisão em Flagrante nº 1500372-37.8.26.0583 (fls. 92/94) e recebida em 07/05/2021 (fls. 95/96).

Pelo C. Superior Tribunal de Justiça foi concedida liminar em habeas corpus para concessão de liberdade ao réu CARLOS EDUARDO (fls. 150/153).

Citados (fls. 112 e 134), os acusados apresentaram respostas à acusação por meio de defensores nomeados (fls. 173/174 e 198/201).

Em 27/07/2021 foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do réu LUIZ GUSTAVO (fl. 178).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 202/204).

Na audiência realizada em 28/10/2021 foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados, tendo havido desistência da oitiva da testemunha Leandro Udenal Guidetti, que não compareceu. Na ocasião, o Ministério Público requereu a juntada aos autos das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e do auto de reconhecimento; a seguir, apresentou alegações orais, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia. Os defensores, por seu turno, pugnaram pela apresentação de alegações escritas (fls. 278/279).

Pela Serventia foi certificada a falta das imagens e auto de reconhecimento (fl. 281), motivo pelo qual foi determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia (fl. 282).

As mídias das fotografias foram disponibilizadas (fl. 288) e o auto de reconhecimento juntado ao feito (fl. 293).

O Ministério Público reiterou as alegações finais oralmente apresentadas (fl. 297). A defesa do réu CARLOS EDUARDO apresentou novas alegações, desta feita escritas, pugnando pela absolvição do réu, argumentando não haver provas suficientes de autoria; em caso de condenação, requereu seja reconhecida a participação de menor importância (fls. 298/305).

Conclusos os autos para sentença, verificou-se a pendência quanto à apresentação de alegações finais pelo réu LUIZ GUSTAVO, motivo pelo qual, foi o julgamento convertido em diligência (fl. 306).

Em memoriais apresentados em 16/08/2022, a defesa do réu LUIZ GUSTAVO requereu a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio

da insignificância; subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da majorante do repouso noturno, porque incompatível com o furto qualificado, e teceu considerações a respeito da aplicação da pena, pugnando pela possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 309/312).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, constata-se que o feito tramitou regularmente, sendo observadas todas as etapas procedimentais, bem como assegurados os direitos e garantias inerentes à defesa. Dessa forma, não havendo nulidades a serem sanadas, tampouco questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11); pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 12/13); pelo Auto de Entrega (fls. 14/15); pelo Auto de Avaliação (fls. 83/84); e, pelas imagens do furto (fl. 288).

No tocante à autoria, necessária detida análise do conjunto probatório.

A vítima Luiz Umberto Feba Fernandes Junior declarou em Juízo que no dia anterior aos fatos, a funcionária responsável por fechar o estabelecimento esqueceu a chave na porta; no dia seguinte, por volta das 9h40min, o réu Luiz Gustavo ("Zé Periquito") passou em frente ao estabelecimento, reparou que a chave estava na porta e aproveitou para entrar no local e furtar o dinheiro que estava na caixa (mais ou menos R\$ 400,00), e às 10h00, o réu retornou ao local com o comparsa e furtou mercadorias, inclusive eles haviam levado mochila e bicicleta para realizar o furto, e dentre os produtos levados estavam ingredientes que eram utilizados para fazer as pizzas (muçarela, calabresa, chocolates etc.) e um celular. Inclusive, o celular foi vendido para um terceiro, este viu o contato da pizzaria cadastrado e entrou em contato, dizendo que havia comprado o celular, e o devolveu mediante o pagamento de R\$ 50,00, que disse ter sido o valor pago pelo aparelho. Disse a vítima, ainda, que também encontraram os produtos alimentícios furtados na mesma manhã, na casa de um dos réus, acredita ser do Carlos Eduardo, o que tem apelido de "Sonoro". Esclareceu que o prejuízo havia sido em torno de R\$ 2.000,00, mas como conseguiu recuperar o celular, o dano diminuiu para algo em torno de R\$ 1.000,00. Contou que, pela análise das câmeras de segurança, o réu apelidado de "Zé Periquito" (Luiz Gustavo) entrou sozinho na pizzaria e furtou apenas o dinheiro; percebendo que era uma situação "fácil", foi embora e voltou com o comparsa, portando a mochila e a bicicleta, para realizar o segundo furto, sendo que ele entrou sozinho novamente na loja, e o comparsa ficou apenas do lado de fora rondando, e entre a saída do primeiro furto e o retorno para o segundo, foram em torno de 15 minutos de intervalo, e isso foi o que ajudou os policiais a analisarem a região e encontrarem a bicicleta e os réus. Informou que a distância entre a casa do réu Carlos Eduardo ("Sonoro") e a pizzaria é curta, de modo que bate com o tempo que levou para o réu Luiz Gustavo sair e voltar com o comparsa.

O Policial Edmilson Volpato relatou que foram acionados por conta de um furto, tendo o proprietário do estabelecimento relatado que a funcionária havia esquecido a chave na porta na noite anterior, e ao adentrar percebeu que estavam faltando R\$ 400,00 do caixa e um aparelho de celular, e analisando as imagens de segurança do local, identificaram o indivíduo que furtou como sendo "Zé Periquito", que entrou a primeira vez, furtou o dinheiro, e depois voltou uma segunda vez para furtar gêneros alimentícios; também identificaram que outro indivíduo ficou do lado de fora no segundo furto, aparentando estar dando cobertura ao comparsa que estava dentro do local realizando o furto, e também foi reconhecido como o Eduardo "Sonoro". Com isso, diligenciaram à residência de Carlos Eduardo e constatarem a presença dos produtos alimentícios furtados, tendo o réu confessado que o outro autor do furto se tratava realmente de "Zé Periquito", além de indicar o endereço deste, onde foi encontrada a bicicleta usada no crime, mas não o réu. Após, foram até a delegacia finalizar a prisão em flagrante do réu Carlos Eduardo. Disse que na análise das imagens internas, constatarem que apenas um ingressou no local e realizou o furto propriamente; pelas imagens externas, viram que o segundo indivíduo apenas estava nas imediações, "dando cobertura", mas em momento algum entrou no local do crime; ademais, o envolvimento do segundo agente estaria somente

no segundo furto, quando o réu Luiz Gustavo volta para furtar os produtos alimentícios; no primeiro furto, do celular e do dinheiro do caixa, o réu Luiz Gustavo aparentava estar sozinho.

De modo semelhante narrou o Policial Agnaldo José da Silva, dizendo que atendeu um caso de furto em pizzaria, cujo funcionário havia esquecido a chave na porta de entrada, e no dia seguinte, constataram a porta aberta e o furto de R\$ 400,00 em dinheiro, um aparelho celular Samsung e gêneros alimentícios. Contou que analisando as imagens da câmera de segurança interna, verificou que o agente era um meliante já conhecido no município, apelidado "Zé Periquito"; nas imagens externas, constatou a presença também de outro agente. Esclareceu que ocorreram duas ações: na primeira, o "Zé Periquito" levou a quantia em dinheiro do caixa e o celular; saiu, e voltou minutos depois para subtrair os gêneros alimentícios, sendo que neste momento constataram a presença do comparsa Eduardo "Sonoro" nas imediações, aparentando dar cobertura para o outro. Com isso, realizaram diligência na casa de Eduardo "Sonoro", onde encontraram parte dos gêneros alimentícios furtados, e indagado, o réu admitiu participação, que o autor do furto era o "Zé Periquito", e informou o endereço deste. Em diligência no endereço informado por ele, constataram a bicicleta utilizada no furto, mas não encontraram o acusado. Após, os policiais apresentaram Eduardo "Sonoro" na delegacia para realizar a prisão em flagrante dele, junto com os objetos encontrados em sua casa. Confirmou que na primeira ocorrência de furto, foram levados o dinheiro e o celular, e na casa do acusado Eduardo "Sonoro", foram encontrados somente os gêneros alimentícios, o celular e o dinheiro não.

Interrogado em Juízo, o acusado LUIZ GUSTAVO, alcunha "Zé Periquito", alegou que estava a caminho da Caixa Econômica Federal para sacar um auxílio, em companhia do réu Carlos Eduardo, quando passaram em frente à pizzaria e o Carlos Eduardo percebeu que o estabelecimento estava com a chave na porta, então pegaram a chave, foram andando até o banco, onde não conseguiram sacar o dinheiro, então voltaram para a pizzaria, tendo Luiz Gustavo adentrado o estabelecimento para realizar o furto, enquanto Carlos Eduardo ficou na esquina, sendo que nessa ocasião levaram R\$ 300,00 em dinheiro e um celular. Na sequência, foram até a casa do "Sonoro", e este disse que "só tinha água na geladeira", então voltaram na pizzaria e pegou produtos alimentícios (calabresa, queijo, chocolates); também compraram pão, e comeram junto com as comidas furtadas. Disse que foi chamado para fazer um serviço, então saiu, e quando retornou, Eduardo "Sonoro" não estava mais na casa pois havia sido levado pela polícia. Confirmou que estiveram na pizzaria duas vezes, na primeira, o réu Carlos Eduardo ficou na esquina para a câmera de segurança não filmá-lo, e Luiz Gustavo entrou sozinho; na segunda vez, Carlos Eduardo ficou em frente à pizzaria, e Luiz Gustavo entrou novamente. Questionado sobre o fim do dinheiro e do celular, disse que deixou na casa de Eduardo "Sonoro", e saiu para fazer o serviço, e quando retornou não conseguiu pegar de volta pois ele já havia sido preso.

O réu CARLOS EDUARDO, vulgo "Sonoro", por seu turno, alegou que saiu para trabalhar com Luiz Gustavo; no serviço, o material que iriam usar chegaria apenas depois do almoço, motivo pelo qual voltaram para casa. Foram até a assistência social para verificar a situação do auxílio emergencial, e foi informado de que receberia na Caixa Econômica Federal. Foram então para sua casa, onde trocou de roupa, e o réu Luiz Gustavo estava morando temporariamente consigo, pois não tinha onde morar; na sequência foram até o banco, e no caminho perceberam que a chave estava na porta da pizzaria, tendo Luiz Gustavo disse que ia ver se a porta estava aberta para poder avisar o dono, então ele foi até ela e pegou a chave, colocando-a no bolso. Disse que continuaram andando até o banco, mas não conseguiu sacar o dinheiro, então voltaram, tendo Carlos Eduardo orientado Luiz Gustavo a devolver a chave, mas este respondeu que não e se sentou em frente à pizzaria. Então, Carlos Eduardo foi para casa, almoçou e foi para uma praça perto de onde mora, e quando subiu de volta para casa, encontrou os policiais em frente à sua residência procurando por Luiz Gustavo, tendo eles adentrado sua residência e lá encontrado os produtos furtados, que acredita que foram deixados por Luiz Gustavo, e por isso foi levado até a delegacia. Alegou ter passado com Luiz Gustavo pela pizzaria apenas no momento em que ele pegou a chave, e não presenciou nenhum dos furtos; supõe que tenha sido

ele, pois ele estava morando temporariamente em sua casa, então poderia ter furtado e deixado as coisas lá.

Do conjunto probatório, verifica-se ser inequívoca a autoria de ambos os furtos, em relação ao réu LUIZ GUSTAVO.

Com relação a CARLOS EDUARDO, não há provas suficientes de que ele tenha participado do primeiro furto (subtração do aparelho celular e do dinheiro); lado outro, há provas robustas de que concorreu para o segundo (furto dos produtos alimentícios), permanecendo do lado de fora, dando cobertura para LUIZ GUSTAVO, enquanto este subtraía os produtos dentro do estabelecimento, o que foi captado pelas câmeras de segurança do local.

No tocante à tipicidade, a conduta dos réus se subsume ao tipo penal do artigo 155, caput, do Código Penal, em relação ao primeiro furto, tendo em vista a ausência de provas de concorrência do corréu para a prática delitiva; e, ao disposto no artigo 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal, quanto ao segundo furto.

Quanto ao réu LUIZ GUSTAVO, por seu turno, de rigor sua absolvição quanto ao primeiro furto, porquanto, como visto, não comprovada sua participação; no que toca ao segundo, sua conduta se subsume ao artigo 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Em qualquer caso, deve ser afastada a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, seja porque os fatos ocorreram durante o dia, entre 09h00 e 10h00 da manhã, conforme informado pela vítima e constatado pelas imagens das câmeras de segurança (fl. 288), seja, ainda, por haver incompatibilidade com o furto qualificado, conforme recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial Repetitivo, com a fixação da tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Ainda, em relação ao réu LUIZ GUSTAVO, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo furto, pois os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, pois se deram no mesmo estabelecimento empresarial, com o mesmo "modus operandi" e em um intervalo de tempo de cerca de 15 minutos, configurando, assim, a continuidade delitiva, conforme previsto no art. 71, caput, do Código Penal.

Observe que o fato de o primeiro furto não ter contado com a participação do corréu (ao menos não há provas nesse sentido) não descaracteriza a similaridade de modus operandi, tendo em vista que, no segundo furto, CARLOS EDUARDO permaneceu do lado de fora dando cobertura para a empreitada, em nada alterando quanto ao agir de LUIZ GUSTAVO.

Noutro giro, não prospera a tese defensiva levantada pela defesa do réu LUIZ GUSTAVO, de aplicação do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância deve ser compreendido como critério de interpretação limitativo dos tipos penais, de forma que, muito embora certas condutas se amoldem formalmente a um tipo legal, não podem ser consideradas penalmente típicas, na medida em que não implicam ofensa significativa ao bem jurídico protegido pela norma.

De acordo com as Cortes Superiores, aliás, o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

No caso em análise, a vítima informou ter sofrido prejuízo financeiro de aproximadamente R\$ 2.000,00, reduzido para R\$ 1.000,00 após a restituição do

celular, valor este que não pode ser considerado insignificante, por muito se aproximar do salário-mínimo.

Ressalto que o auto de avaliação de fls. 83/84 diz respeito apenas aos produtos alimentícios encontrados na casa de CARLOS EDUARDO, após a consumação de uma parte, e sem contar o valor em dinheiro também furtado.

No entanto, ainda que se leve em consideração apenas o valor declinado no auto de avaliação de fls. 83/84 (R\$ 290,00), igualmente não há como ser reconhecida a insignificância, uma vez que correspondente a 26,36% do salário-mínimo vigente na data dos fatos <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>, valor este que não pode ser considerado insignificante.

Ademais, o crime foi praticado em concurso de agentes, tratando-se, assim, de furto qualificado que, consoante precedentes do E. TJSP, obsta a aplicação do princípio da insignificância:

"(...) Ademais, o réu praticou o furto em sua modalidade qualificada, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes do TJSP. Condenação de rigor. Dosimetria. Basilar acima do mínimo, contudo, necessária a diminuição do aumento. Reincidência comprovada. Compensação integral com a atenuante da confissão. Circunstâncias de mesma grandeza. Regime semiaberto mais adequado e proporcional. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15001967320218260578 SP 1500196-73.2021.8.26.0578, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 19/10/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021)

FURTO QUALIFICADO TENTADO. Absolvição em 1º Grau fundada no "Princípio da Insignificância". Inadmissibilidade. Conduta típica. Tentativa de subtração de fios de cobre. Reprovabilidade do comportamento. Apelo ministerial provido. (TJ-SP - APR: 00000488520148260157 SP 0000048-85.2014.8.26.0157, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 21/10/2021, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2021)

Se não bastasse, das Folhas de Antecedentes de fls. 113/120 e 121/132 verifica-se que os réus são reincidentes. Assim sendo, estão ausentes pelo menos dois dos requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, que são cumulativos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, motivo pelo qual, afasto a tese defensiva.

Por fim, melhor sorte não socorre à defesa do réu CARLOS EDUARDO ao alegar participação de menor importância.

Isso porque, a análise da tese de participação de menor importância deve ser feita observando a divisão de tarefas dada entre os acusados e o liame subjetivo estabelecido entre ambos. Logo, ainda que CARLOS EDUARDO tenha ficado apenas observando o local para que terceiros não impedissem a prática criminosa, observa-se que houve na verdade uma divisão de tarefas entre eles, cabendo a cada qual parte da execução do iter criminis, com relevância inclusive para a sua consumação.

Observa-se que CARLOS EDUARDO, no seu ato de vigília, tinha o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo comparsa, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Houve, na verdade, divisão de tarefas, pluralidade de condutas, relevância das ações e liame subjetivo entre os agentes, sabendo cada qual o que deveria fazer e o que seu comparsa faria. Tais características estão a indicar a ocorrência de coautoria e não participação.

Em casos semelhantes, nesse sentido é a jurisprudência: Direito Penal. Furto. Participação de menor importância. Inocorrência. Réu que permanece fora do imóvel vigiando o local. Auxílio relevante para a consumação do delito. Redução de pena incabível. (TJ-SP - APL: 00000854520138260320 SP 0000085-45.2013.8.26.0320, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/09/2015, 6ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 13/09/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM

participação de menor importância. Isso porque, a análise da tese de participação de menor importância deve ser feita observando a divisão de tarefas dada entre os acusados e o liame subjetivo estabelecido entre ambos. Logo, ainda que CARLOS EDUARDO tenha ficado apenas observando o local para que terceiros não impedissem a prática criminosa, observa-se que houve na verdade uma divisão de tarefas entre eles, cabendo a cada qual parte da execução do iter criminis, com relevância inclusive para a sua consumação. Observa-se que CARLOS EDUARDO, no seu ato de vigília, tinha o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo comparsa, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Houve, na verdade, divisão de tarefas, pluralidade de condutas, relevância das ações e liame subjetivo entre os agentes, sabendo cada qual o que deveria fazer e o que seu comparsa faria. Tais características estão a indicar a ocorrência de coautoria e não participação.

ERRO DE TIPO, POIS NÃO TINHA CIÊNCIA DE QUE SEU CUNHADO ESTAVA FURTANDO A MOTOCICLETA. INVIABILIDADE. RÉU QUE APRESENTOU VERSÕES DIVERGENTES EM SEUS INTERROGATÓRIOS. POLICIAIS MILITARES QUE FORAM ACIONADOS APÓS CRIME E VISUALIZARAM A CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO LOCAL, TENDO VERIFICADO QUE O FURTO FOI PERPETRADO PELO RÉU E MAIS OUTRA PESSOA. AGENTES PÚBLICOS QUE, AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA, SOB ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ATUOU DE FORMA DECISIVA NA EXECUÇÃO DO DELITO. FUNÇÃO DE OLHEIRO, DANDO COBERTURA E PROPICIANDO A CONSECUÇÃO DO ILÍCITO. "Incogitável reconhecer a participação de menor importância do réu quando comprovado que esteve em conluio durante toda a empreitada criminosa e que participou, na qualidade de coautor, da execução do plano, exercendo a tarefa que lhe incumbia dentro do projeto delitivo, objetivando o sucesso da operação ilícita. (TJ-SC - APR: 00001471620128240049 Pinhalzinho 0000147-16.2012.8.24.0049, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 20/09/2018, Quinta Câmara Criminal)

Frise-se que os réus eram imputáveis na data dos fatos, tinham pleno conhecimento acerca do caráter ilícito de suas condutas, e não há quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade que possam beneficiá-los.

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao réu LUIZ GUSTAVO, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há motivo para valoração da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, analisando a F.A. de fls. 121/132 em concomitância com informações colhidas junto ao E-SAJ, verifica-se que o réu possui as seguintes condenações: a) autos nº 0004211-84.2014.8.26.0456, pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 16/03/2017; b) autos nº 0000428-26.2010.8.26.0456, pelo crime de furto, tendo a sentença transitado em julgado em 16/01/2012; c) autos nº 0003871-19.2009.8.26.0456, pelo crime de furto, cuja sentença transitou em julgado em 09/12/2012; d) autos nº 0003695-40.2009.8.26.0456, pelo crime de furto, tendo a sentença transitado em julgado em 08/11/2010; e) autos nº 0002810-26.2009.8.26.0456, pelo delito de furto, cuja sentença transitou em julgado em 18/01/2011; e, f) autos nº 0000383-56.2009.8.26.0456, pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 03/11/2010. Observo a F.A. que as penas foram unificadas e possuíam término previsto para 02/05/2022, o que não aconteceu, devido à prisão preventiva do acusado neste processo. Assim sendo, valho-me das condenações decorrentes dos autos nº 0003871-19.2009.8.26.0456, nº 0003695-40.2009.8.26.0456, nº 0002810-26.2009.8.26.0456 e nº 0000383-56.2009.8.26.0456 para exasperar a pena-base, em virtude de maus antecedentes. Os motivos do crime não restaram esclarecidos. As consequências dos delitos não justificam acréscimo. As circunstâncias em que o crime ocorreu são normais. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não enseja valoração. Não há dados nos autos suficientes a permitirem avaliação acerca da personalidade do agente. Por fim, a vítima não contribuiu para a prática do delito. Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável e, ao mesmo tempo, as diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o furto simples; e, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o furto qualificado.

Na segunda fase, concorrem atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), especificamente quanto às condenações decorrentes dos autos nº 0004211-84.2014.8.26.0456 e nº 0000428-26.2010.8.26.0456. Tratando-se de múltipla

reincidência, deve prevalecer a agravante da reincidência, de modo que deixo de compensá-las e, conseqüentemente, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o furto simples; e, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias para de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o furto qualificado. Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o furto simples; e, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias para de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o furto qualificado. Conforme visto na fundamentação, incide ao caso a regra da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal. Assim sendo, deve ser aplicada apenas a pena mais grave, aumentada em 1/6 (por terem sido dois os crimes continuados). Desta feita, fixo a pena final em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, observado, quanto aos dias-multa, o disposto no artigo 72 do Código Penal.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devido à frágil situação econômica do réu (art. 49, § 1º, do CP).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

A despeito da quantidade de pena aplicada, considerando a reincidência do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Observo que, diante da reincidência do réu, o tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime (art. 387, § 2º, do CPP), devendo ser computado para fim de detração pelo juízo da execução.

A reincidência do agente obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que igualmente não se mostram recomendáveis, e a concessão do "sursis" (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Em relação ao réu CARLOS EDUARDO, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há motivo para valoração da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, analisando a F.A. de fls. 41/42 em concomitância com informações colhidas junto ao E-SAJ, verifica-se que o réu possui as seguintes condenações: a) autos nº 0000457-10.2015.8.26.0583, pelo crime de furto, cuja sentença transitou em julgado em 13/04/2016; e, b) 0000846-80.2018.8.26.0456, pelo crime de ameaça, tendo a sentença transitado em julgado em 09/11/2018. Assim sendo, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 0000846-80.2018.8.26.0456 para exasperar a pena-base, em virtude de maus antecedentes. Os motivos do crime não restaram esclarecidos. As consequências dos delitos não justificam acréscimo. As circunstâncias em que o crime ocorreu são normais. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não enseja valoração. Não há dados nos autos suficientes a permitirem avaliação acerca da personalidade do agente. Por fim, a vítima não contribuiu para a prática do delito. Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há qualquer atenuante a ser aplicada. Em contrapartida, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), especificamente quanto à condenação decorrentes dos autos nº 0000457-10.2015.8.26.0583. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias para de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição, de modo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias para de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devido à

frágil situação econômica do réu (art. 49, § 1º, do CP).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

A despeito da quantidade de pena aplicada, considerando a reincidência do réu e a existência de maus antecedentes, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Observo que, diante da reincidência do réu, o tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime (art. 387, § 2º, do CPP), devendo ser computado para fim de detração pelo juízo da execução.

A reincidência específica do agente obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do "sursis" (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

a) CONDENAR o réu LUIZ GUSTAVO CAETANO DA SILVA, RG nº 47471151/SP, natural de Pirapozinho/SP, nascido aos 02/09/1990, filho de Devanir Caetano da Silva, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, e no artigo 155, § 2º, inciso IV, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos;

b) CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA, RG nº 29343363/SP, CPF 206.309.118-86, natural de Junqueirópolis, nascido aos 06/02/1978, filho de Maria Aparecida Xavier da Silva e de José Carlos da Silva, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias para de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos; e, ABSOLVÊ-LO quanto ao primeiro furto, também tipificado no artigo 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu CARLOS EDUARDO respondeu ao processo todo em liberdade, nessa condição poderá permanecer para recorrer.

Quanto ao réu LUIZ GUSTAVO, porém, considerando que respondeu ao processo todo preso, que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como que ainda estava em cumprimento de pena por ocasião de sua prisão, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Não houve pedido formulado pela acusação de reparação de danos sofridos pela vítima, de modo que a fixação ex officio de valor mínimo indenizatório prejudicaria o exercício da ampla defesa por parte do réu, já que não teria a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, de modo a indicarem valor diverso ou mesmo apontar que inexistiu prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 742). Assim, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos.

Condeno os réus, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, por estarem assistidos por defensores nomeados, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Notifique-se a vítima sobre o teor da presente sentença condenatória, nos termos do artigo 201, §2º do CPP.

Arbitro honorários aos defensores nomeados em 100% do valor previsto na tabela do Convênio OAB/DPE. Expeçam-se as certidões.

Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se mandados de prisão em regime fechado e guias de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação dos réus, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, e) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação". Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Pirapozinho, 27 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA